

1500223-54.2021.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... comprovam a dedicação do acusado ao tráfico de drogas, conclusão assentada com base no interrogatório do acusado e no depoimento das testemunhas de acusação, em juízo, ao afirmarem que o acusado se dedicava ao tráfico há, pelo menos, uma semana. Além disso, o acusado confirmou que vivia do tráfico. Com efeito, a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500223-54.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500223-54.2021.8.26.0611

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

Ministério Público

Réu:

LUCAS MARCELINO TAVARES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra LUCAS MARCELINO TAVARES, por infração aos artigos 150, caput, do Código Penal e, 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, em data compreendida entre os dias 20 e 29 de outubro de 2021, na Rua Marcília Mingoni Tuzi, nº 146, Residencial Espigão, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, permanecer, contra a vontade expressa de Irma Alves de Oliveira Paulista, em casa alheia ou em suas dependências; bem como de nas mesmas circunstâncias de tempo espaço, guardar, com finalidade mercantil, 15 (quinze) porções de cocaína, com peso aproximado de 1,72g, conforme laudo de constatação provisória, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como R\$ 92,00 (noventa e dois reais) em espécie (f.127/131).

O acusado foi preso em flagrante delito. Decisão de f.70/71 homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do réu (f. 53/60).

A defesa apresentou defesa prévia (f.145).

Decisão de f.148/151 recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, e, ao final, interrogado o acusado. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação, no exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, e da confissão espontânea, bem como, a absolvição quanto ao delito de invasão de domicílio (f.218/222).

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido.

A fim de evitar repetições desnecessárias, transcrevo o teor da prova oral, como segue:

A vítima IRMA ALVES DE OLIVEIRA PAULINO, ouvida em juízo, relatou que é proprietária do imóvel onde os fatos ocorreram. O acusado residia no local, que foi invadido. Seu filho costumava locar a residência. Falou com o acusado para a devolução do imóvel, porém LUCAS se negou a deixar o local, por ter afirmado que seu filho havia alugado o imóvel. Ficou quatro meses fora do imóvel. Ouviu comentários que a casa estava sendo utilizada para o comércio de entorpecentes (mídia digital).

A testemunha THIAGO ROBERTO TOGNATI SILVEIRA, policial militar, ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos foram procurados por uma senhora que relatou que seu filho havia se apropriado de seu imóvel e, fazia comércio de entorpecentes no local e, permitia que os usuários ali consumissem as drogas, foi preso juntamente com LUCAS. No entanto, o acusado foi liberto e passou a comandar o comércio de drogas no local. No imóvel encontraram LUCAS, vulgo "Guará", na companhia de outras pessoas, durante revista pessoal nada de ilícito foi localizado. No quarto do acusado, sobre o travesseiro na cama, foram encontradas 15 pedras de crack; sobre a cômoda, um prato com resquícios de crack e duas laminas de "gillette", R\$ 92,00 (noventa e dois reais), 4 (quatro) pulseiras de prata, o celular de uso pessoal de LUCAS e um Iphone, de cor rosa. Durante o percurso até a delegacia, o acusado afirmava em tom ameaçador que sabia quem havia feito a denúncia, referindo-se assim à IRMA. Outras denúncias narravam sobre o fato de LUCAS ter assumido a "biqueira" que pertencia a EDWAGNER, e que, estava fazendo o comércio de entorpecentes no local, franqueando o consumo das substâncias no interior do imóvel. O réu afirmou que havia locado a residência (mídia digital).

A testemunha MARCOS ANTÔNIO GOMES FILHO, policial militar, ouvido em juízo, narrou que no dia dos fatos foram procurados por IRMA que relatou que, semanas antes do ocorrido, seu filho havia sido preso por tráfico com LUCAS. A senhora narrou ainda que seu filho havia feito com que ela deixasse de residir no imóvel. Ao ser liberto, LUCAS passou a residir no local e assumiu o comércio de drogas ali existente. IRMA franqueou a entrada dos policiais no local. Na residência localizaram o réu e outras pessoas, algumas delas usuárias de drogas. No quarto do acusado foram localizadas 15 (quinze) porções de crack, R\$ 92,00 (noventa e dois reais), um prato com duas "gillettes" e resquícios de entorpecentes, além de um aparelho celular de cor rosa, marca Iphone, este último que não pertencia a nenhum

dos indivíduos que ali estavam. O celular do acusado também foi apreendido. Um mês antes dos fatos, a equipe policial surpreendeu LUCAS, EDWAGNER e FELIPE, praticando o tráfico de drogas no local. Recebiam denúncias com frequência sobre as práticas de tráfico por LUCAS e que tinha assumido a biqueira. Em outra ocorrência o acusado ameaçou o declarante de morte, afirmando que chamaria o PCC. No dia dos fatos dizia que sabia quem havia denunciado e que "não iria ficar assim"(mídia digital).

O acusado LUCAS MARCELINO TAVARES, interrogado juízo, revelou que um dos celulares apreendidos era de seu uso pessoal, utilizava inclusive para conversar com a filha da vítima, KELLY, que havia autorizado sua estadia no local até o dia 29. Não sabe a quem pertencia o outro aparelho celular localizado no imóvel. KELLY inclusive estava ajudando o acusado a encontrar outro imóvel para residir. Admitiu a venda de entorpecentes. Comercializou os itens por cerca de 2 (duas) semanas, pois estava desempregado. Acredita que tenha vendido cerca de 5 pedras de crack. Com relação a quantia em dinheiro encontrada no local, narrou que da importância de R\$92,00, R\$50,00 era resultado do tráfico e o restante já lhe pertencia. Sobre o consumo de drogas no local, a pessoa que fazia uso de entorpecentes no interior da residência era ANDERSON, sobrinho de IRMA (mídia digital).

Esse é o teor da prova oral.

II.I.DO CRIME DE TRÁFICO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006)

O Ministério Público acusa LUCAS MARCELINO TAVARES de praticar o crime definido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que cuida do denominado delito de "tráfico de drogas" possui a seguinte redação:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Penal - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluo que há provas seguras de que o acusado efetivamente trazia consigo cocaína, substância narcótica proscribida pela legislação brasileira, com o escopo de promover a difusão ilícita dela. Com efeito, a cláusula do devido processo legal e o princípio da presunção de inocência exigem que o órgão oficial de acusação suporte o inteiro ônus da prova de culpabilidade do réu, além de uma dúvida razoável (beyond a reasonable doubt). A mera dúvida resolve o processo em favor do acusado. "A presunção de inocência, princípio cardinal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.", consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

No caso concreto, o Ministério Público logrou provar a procedência da acusação.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (f.01), o boletim de ocorrência de f.10/15, o auto de exibição e apreensão de f. 18/20, o laudo de constatação provisório (f. 23/25), o laudo toxicológico definitivo (f. 102/104), pelos laudos de f.105/108 e 109/111, bem como por toda a prova oral colhida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inegável e incontroverso que a substância apreendida é o narcótico "cocaína".

A autoria, a seu turno, é certa, com farta prova documental e oral, em especial pela confissão em juízo.

Nesse contexto, o cotejo analítico da prova indica que a autoria é certa, com farta prova documental e oral, recaindo sobre o acusado.

Os policiais foram claros e demonstraram com fidelidade a narrativa dos fatos, bem como a apreensão em flagrante do acusado guardando as drogas apreendidas.

O laudo definitivo de f. 102/104 evidenciou a presença do composto químico METIL BENZOIL ECGONINA (cocaína) nos materiais analisados. Substância que se encontram relacionadas na Lista "F" da Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como drogas entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

Nessa quadra, joeirado o acervo probatório, tenho que ficou provado que o acusado era o proprietário das drogas e agia em nítida ação de tráfico de drogas. Com efeito, os policiais relataram que receberam denúncia da proprietária do imóvel, dando conta do tráfico de drogas no local, e imputando ao acusado a prática da mercancia de droga no local. De posse das informações, deslocaram ao local e encontraram o acusado nas circunstâncias registradas na delação. Ressalto ainda que todos os dados informados na denúncia foram constatados pelos policiais e que seus depoimentos estão de acordo com as demais provas do processo.

Além disso, foram apreendidas várias porções de cocaína, reforçando a conclusão de prática do tráfico em detrimento da mera posse para consumo pessoal. A quantidade de drogas localizada com o acusado não é normal de ser identificada com viciados. Ademais, o próprio acusado confirmou que as drogas seriam destinadas ao tráfico.

A prova deve ser valorada dentro do contexto em que ocorreram os fatos, com os pés no chão e olhos na realidade, valorizando-se os indícios, que sempre foram reconhecidos como elementos de convicção.

Urge assentar que os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso). Assim, quem trazia consigo 15 porções de cocaína prática, de forma hialina, o crime de tráfico de drogas.

De mais a mais, sabe-se que a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função investigativa, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço. Sobre a validade dos testemunhos insuspeitos dos policiais, vejamos a farta orientação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação

investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.

3. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Desconstituir o julgamento da Corte a quo, que condenou as agravantes pelo crime de tráfico de drogas, ou aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, demandaria a incursão na seara fático/probatória, situação inviável ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONSIDERADO NOTÓRIO. COTEJO ANALÍTICO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS. VALIDADE.

2. O alegado dissenso pretoriano deve ser demonstrado conforme preconizado nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, mesmo em se tratando de dissídio considerado notório.

3. É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 482.641/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014)

Os testemunhos dos policiais estão em harmonia com as provas produzidas, especialmente pela confissão do acusado, e pelo laudo toxicológico que atestou que o material apreendido se trata de cocaína.

Ainda sobre a credibilidade do testemunho dos policiais militares, julgo apropriado rememorar a preleção do Ministro CELSO DE MELLO:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC - 74.608-0 - de São Paulo - rel. Min. Celso de Mello - DJU 11.04.97, pág. 12.189).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o fato de o acusado ser surpreendido na posse de drogas, após insuspeita delação, é suficiente para justificar o desfecho condenatório. A propósito, colho os seguintes precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"EMENTA: Tráfico de entorpecentes. Policiais militares que, após denúncia anônima de que um indivíduo estaria praticando tráfico de entorpecentes, dirigem-se até o

local, onde avistam o réu, que trajava as mesmas roupas informadas pela denúncia. Milicianos que permanecem escondidos atrás de uma cerca viva, oportunidade em que visualizam a aproximação de um rapaz em uma motocicleta, que conversa com o acusado e então passa a dar voltas no quarteirão. Réu que se dirige até um banco de areia localizado em um terreno baldio e, ao retornar, entrega droga ao rapaz da motocicleta, que levanta o "eppendorf" contra a luz, permitindo que os policiais constatem se tratar de cocaína. Policiais que decidem realizar a abordagem, momento em que avistam o réu recebendo dinheiro de outro indivíduo, que se encontrava no interior de um veículo e fugiu ao perceber a presença da polícia. Apreensão da quantia de R\$ 11,50 no bolso do acusado, e de 44 porções de cocaína, que se encontravam no referido banco de areia. Palavras dos policiais coerentes e seguras, dando conta da apreensão das drogas. Negativa do acusado isolada. Postura de quem se valia da droga para a mercancia. Condenação de rigor. Desclassificação inviável. Penas bem dosadas. Hipótese que não autorizava mesmo a redução pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Impossibilidade de substituição da pena. Regime fechado adequado (Lei n.º 11.464/07). Apelo improvido. (Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Araras; Órgão julgador: 7ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2017; Data de registro: 12/04/2017)".

"EMENTA: Tráfico de Entorpecentes. Policiais militares que, após diversas denúncias anônimas recebidas pela polícia civil e militar dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes, receberam a notícia de que ele estaria embalando e comercializando drogas na praça central da cidade, dirigindo-se até o local. Acusado que, ao perceber a aproximação dos milicianos, foge em direção a uma escola e, na iminência de ser detido, joga duas porções de cocaína em seu interior. Em revista pessoal, os policiais localizam embalagens plásticas vazias e um aparelho celular. Posteriormente, ao entrarem na escola, encontram as porções de cocaína. Os policiais ainda refazem o caminho percorrido pelo réu durante a perseguição, ocasião em que localizam outras duas porções de substância aparentando ser cocaína, além de uma tesoura. Palavras dos agentes públicos coerentes e seguras. Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Prova oral hábil. Condenação pelo tráfico bem decretada. Penas revistas, afastado o aumento da base e aplicado, excepcionalmente, o redutor do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em 1/2. Regime fechado absolutamente necessário. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido. (Relator(a): Pinheiro Franco; Comarca: Monte Alto; Órgão julgador: 7ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 12/04/2017; Data de registro: 12/04/2017)"

"EMENTA: Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de droga e denúncia anônima – Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva – Apelo parcialmente provido. (Relator(a): Rachid Vaz de Almeida; Comarca: São Joaquim da Barra; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 23/02/2017; Data de registro: 01/03/2017)."

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de guardar a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC nº 69.806/00- Relator Ministro

CELSO DE MELLO - In DJU 04.06.1993 - p. 11.012).

Assim, todos esses elementos somados, a quantidade de drogas, o modo de acondicionamento dos entorpecentes, deságuam com segurança o propósito de mercancia e de difusão ilícita da maconha, não obstante, enfatizo, o tipo penal do artigo 33 ser congruente.

Destarte, todos esses elementos somados, a quantidade de drogas, o modo de acondicionamento dos entorpecentes, a quantidade de dinheiro apreendida e a confissão do acusado, deságuam com segurança o propósito de mercancia e de difusão ilícita das drogas, não obstante, enfatizo, o tipo penal do artigo 33 ser congruente.

Logo, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a condenação é de rigor, não havendo o que se falar em insuficiência de provas.

Afasto a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porque as evidências comprovam a dedicação do acusado ao tráfico de drogas, conclusão assentada com base no interrogatório do acusado e no depoimento das testemunhas de acusação, em juízo, ao afirmarem que o acusado se dedicava ao tráfico há, pelo menos, uma semana. Além disso, o acusado confirmou que vivia do tráfico. Com efeito, a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, alcançando o traficante eventual ou episódico, o que não é o caso do acusado, flagrado na posse de grande quantidade de droga de alto valor no mercado negro e de expressiva quantia auferida com o tráfico.

Assim, assentado o tráfico de drogas, todas as evidências demonstram que o dinheiro apreendido é proveito do tráfico, pelo que deve ser decretado seu perdimento. Quando a Defesa tomou conhecimento do auto de exibição e apreensão, poderia ter demonstrado a origem lícita do numerário, até sentença final, o que não ocorreu. O perdimento do dinheiro é corolário lógico, na forma determinada pelo artigo 63, § 1º, da Lei Federal 11.343/06, e até mesmo em função do art. 92, II, letra a e b, do Código Penal. Não há provas seguras da origem lícita do dinheiro, o que autoriza, a princípio, a conclusão de que o dinheiro é produto do crime de tráfico, não desincumbindo-se o acusado do ônus que lhe competia de provar o contrário.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação nos termos da denúncia.

II.II.DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)

O Ministério Público acusa LUCAS MARCELINO TAVARES de praticar o crime definido no artigo 150, caput, do Código Penal.

O artigo 150, caput, do Código Penal que cuida do denominado delito de "violação de domicílio" que possui a seguinte redação:

"Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência."

Dessa forma, o cotejo da prova oral, com as evidências materiais recolhidas pela polícia na fase de investigação, são insuficientes para demonstrar, acima de uma dúvida razoável, que o acusado realizou o delito narrado.

Assim, é o caso de absolver o acusado por falta de provas, na medida em que não há provas judicializadas no sentido de que o acusado de fato tenha invadido o domicílio da vítima. Salientando que o imóvel estava inabitado há mais de quatro meses.

Ademais, segundo o acusado, ele obteve autorização da filha da vítima para habitar o imóvel, com o consentimento da vítima, não havendo provas em sentido contrário.

Insta salientar, que com base na prova oral colhida em juízo, não qualquer evidência de o acusado tenha praticado o delito. Assim, considerar que o Ministério Público, titular da ação penal, não cuidou de produzir provas em juízo suficientes em juízo, o caso é de absolvição por falta de provas.

O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos recolhidos na fase policial, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A Constituição da República estabeleceu como direito civil a impossibilidade de alguém vir a ser privado de sua liberdade sem o devido processo legal, insculpida no seu artigo 5º, inciso LIV, do qual resulta a necessidade de julgamento perante Juiz previsto em lei e que seja observado um procedimento de determinação dos fatos, com contraditório, cabendo ao Estado o exclusivo ônus de produzir provas da procedência da proposição acusatória.

Nesse contexto, as informações recolhidas pela autoridade policial não podem servir de fundamento exclusivo para o decreto condenatório.

Nesse sentido, confirmam-se as lições doutrinárias:

"(...) O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, não poderá deixar de influir no espírito do juiz na formação de seu livre convencimento para o julgamento da causa, mesmo porque integra os autos do processo, podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase extrajudicial. Como bem assinala Silvio Di Filippo, de acordo com o princípio do livre convencimento que informa o sistema processual penal, as circunstâncias indicadas nas informações da polícia podem constituir elementos válidos para a formação do convencimento do magistrado. Certamente, o inquérito serve para colheita de dados circunstanciais que podem ser comprovados ou corroborados pela prova judicial e de elemento subsidiário para reforçar o que for apurado em juízo. Não se pode, porém, fundamentar uma decisão condenatória apoiada exclusivamente no inquérito policial, o que contraria o princípio constitucional do contraditório. Essa conclusão ficou reforçada com as garantias processuais estabelecidas pela Constituição de 1988, embora já presente na jurisprudência." (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 83.)

Confira-se, a propósito, os comentários de Antônio Magalhães Gomes Filho:

"Ao dizer que o juiz formará o seu convencimento pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, excluindo, ao mesmo tempo, que possa utilizar exclusivamente elementos informativos colhidos na investigação, o legislador consagrou e sublinhou a nítida e apropriada distinção entre o que é prova e aquilo que constitui elemento informativo da investigação. São, com efeito, conceitos que não se confundem, até porque constituem resultado de atividades com finalidades diversas: os atos de prova objetivam a introdução de dados probatórios (elementos de prova) no processo, que servem à formulação de um

juízo de certeza próprio da sentença; os atos de investigação visam à obtenção de informações que levam a um juízo de probabilidade idôneo a sustentar a opinião delicti do órgão da acusação ou de fundamentar a adoção de medidas cautelares pelo juiz. A Lei 11.690/2008, ao tornar explícita essa diferença essencial entre prova e elemento informativo trazido pela investigação, ressalta que a observância do contraditório é verdadeira condição de existência da prova." (FILHO, Antonio Magalhães Gomes; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis (Coord.). AS reformas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 250.)

O aludido doutrinador estabelece, ainda, interessante distinção entre o método inquisitório e o contraditório para a produção dos elementos probatórios, nestes termos:

"No método inquisitório a pesquisa dos fatos é conduzida unilateralmente, com o propósito de confirmar, a todo preço e custo, uma hipótese de verdade previamente estabelecida pelo inquisidor, o que traz em si grave vício epistemológico. Ao contrário, o sistema informado pelo contraditório, permitindo a cada uma das partes apresentar provas contrárias para trazer elementos de confronto em relação às provas do adversário, enriquece-se o material probatório à disposição do juiz, aumentando a base cognitiva para o estabelecimento da verdade sobre os fatos." (op. cit. p. 251.)

Acerca da condenação pautada unicamente em provas produzidas no decorrer do inquérito policial, assim se posiciona a abalizada doutrina do professor GUILHERME DE SOUZA NUCCI: "A doutrina e a jurisprudência sempre firmaram tal entendimento: a prova colhida durante a investigação, para ser utilizada em juízo, precisa ser confirmada por outras provas, coletadas sob o crivo do contraditório. Em conclusão, as provas colhidas durante a investigação não servem para lastrear uma decisão condenatória. Quando levadas em conta, precisam ser firmemente ratificadas por provas coletadas sob o contraditório judicial" (NUCCI, Guilherme de Souza, Tratado Jurisprudencial e Doutrinário em Direito Processual Penal, RT, p. 60).

O processo justo pressupõe que a determinação judicial dos fatos leve em consideração provas produzidas em contraditório, o que, ao fim e ao cabo, além de ser um imperativo categórico do direito de defesa, é uma importante ferramenta de distribuição dos riscos de uma condenação injusta ou de erro judiciário. Conforme sábia lição de ROXIN, o processo penal é sismógrafo da Constituição e o processo penal democrático, voltado para a proteção dos direitos fundamentais, impõe a distribuição assimétrica dos riscos do erro judiciário, imputando ao Estado o exclusivo ônus de provar, em Juízo, a procedência da proposição acusatória.

Nosso sistema processual é democrático e a política estabelecida pelo legislador é de que o Estado deve suportar em maior grau o risco de erro judiciário. Disso resulta o princípio da não culpabilidade, que impõe a absolvição em caso de dúvida da proposição acusatória, que o nível de prova exigido para fundamentar uma condenação tem que ser elevado (acima de uma dúvida razoável) e que condenações judiciais não podem ser motivadas apenas em elementos de informação recolhidos na fase policial.

A propósito do artigo 155 do Código de Processo Penal, cito os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.

1. O inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante ao indiciado o exercício da ampla defesa, afigurando-se, portanto, nulo o decreto condenatório que não produz, ao

longo da instrução criminal, qualquer outra prova hábil para fundamentá-lo. Precedentes desta Corte.

2. O Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo ministerial para condenar os Pacientes, amparou-se no auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, bem como na confissão extrajudicial de um dos acusados, que não restou ratificada em juízo. Não houve, assim, qualquer prova desfavorável produzida na fase judicial, evidenciado, com isso, flagrante constrangimento ilegal na condenação imposta.

3. Ordem concedida para, cassando o acórdão atacado, restabelecer a sentença de primeiro grau que absolveu os ora Pacientes. (HC 112.577/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 213 C/C ART. 224, ALÍNEA A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PROFERIDA COM BASE EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.

I - É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se admite condenação baseada, exclusivamente, em provas colhidas na fase policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório (Precedentes).

II - Na espécie, o acórdão que reformou a sentença absolutória baseou-se exclusivamente em declarações e depoimentos prestados em inquérito policial, não confirmados em Juízo, o que não se mostra suficiente para embasar a condenação.

Recurso especial provido. (REsp 1070482/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 05/10/2009)

Destarte, inviável escorar condenação em exclusivas evidências coletadas durante investigação criminal, sequer ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do preceituado pelo art. 155 do Código de Processo Penal

III - DISPOSITIVO

Na confluência do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o acusado LUCAS MARCELINO TAVARES nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e para ABSOLVER-LO da acusação de praticar o delito do artigo 150, caput, do Código Penal.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal do acusado, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

A culpabilidade é normal. O réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade do acusado é desajustada, posto que durante abordagem policial o acusado ameaçou um dos policiais de morte (ver depoimento de MARCOS ANTÔNIO, transcrito nesta sentença). Quem tem a audácia de ameaçar policiais armados expõe personalidade violenta, agressiva, autorizando a glosa nesta fase da dosimetria. Motivo do crime normal. Circunstâncias graves, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendida, de elevado valor no mercado negro e grande poder de vício, circunstância preponderante nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Consequências normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819).

Presentes duas vetoriais negativas, a princípio, cada circunstância judicial desfavorável deve levar a um acréscimo correspondente a 1/8 do apurado entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao delito. Entretanto, o referido critério serve como uma baliza, não é matemático, devendo ser ponderado no caso concreto. Dessa forma, a personalidade deve gerar o referido aumento de 1/8, entretanto, as circunstâncias, por serem preponderantes, diante da elevada quantidade de droga apreendida, conforme artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, deve gerar um aumento

de 1/3. Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 791 dias-multa.

Concorrem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (réu menor de 21 anos na data do fato), razão pela qual diminuo a pena à razão de um quinto, dosando-a em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 24 dias de reclusão e 632 dias-multa.

Inexistentes outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Não estão satisfeitos os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, como já fundamentado.

Fica o réu definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 24 dias de reclusão e 632 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal), fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP) em razão da pena fixada.

A considerar a dedicação do acusado ao tráfico de drogas, como anteriormente fundamentado, urge proteger a ordem pública e evitar recidivas criminais, pelo que mantenho o acusado preso preventivamente. Todavia, fixado o regime semiaberto, a custódia cautelar deve ser ajustada ao regime inicial de cumprimento de pena, providência a ser tomada pelo diretor do estabelecimento onde se encontra. Oficie-se requisitando a transferência do réu para estabelecimento de cumprimento de semiaberto, no prazo de 10 dias.

O período de prisão preventiva do acusado será considerado para definir o regime de cumprimento da pena, cujos cálculos serão realizados na fase de execução. Contudo, conforme artigo 387, § 2º, do CPP, constato que ele não alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Se interposto recurso, EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Determino, outrossim, o perdimento em favor da União do dinheiro depositado à disposição desse juízo, nos termos da Lei nº 11.343/06, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação

relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde o réu deve cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário.

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

d) Oficie-se a SENAD a respeito do perdimento.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 17 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA